

1500855-91.2021.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... que o réu estava no local praticando o tráfico de drogas, conforme a denúncia repassada aos policiais. Também havia o dinheiro de origem desconhecida e o local é ponto de tráfico de drogas. O réu é primário e não se opõe à fixação da pena no patamar mínimo. Por outro lado, requer a fixação do regime fechado, sendo vedada a conversão.

A defesa insiste na desclassificação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500855-91.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500855-91.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302761/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 21247989 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 1000/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2302761 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1000/21/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN MATEUS TEIXEIRA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal contra Jonathan Mateus Teixeira de Paula, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 20h50, na Rua Otávio Cury, Vale do Redentor IV, nesta cidade e Comarca,

vendia, trazia consigo e guardava 06 (seis) porções de maconha, pesando 63,50 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 77/78 veio amparada no Inquérito Policial – Prisão em Flagrante – de págs. 01/23.

A prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória (págs. 34/39).

O réu foi notificado (págs. 87) e apresentou defesa preliminar (págs. 66/67), aduzindo, em síntese, a inexistência de provas do qual indicam que acusado tinha a intenção de vender drogas. Requer a substituição da pena privativa por pena restritiva de direito. Informa ser usuário de drogas.

A denúncia foi recebida aos 18 de março de 2022 e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 107/109).

Durante referida solenidade realizada aos 24 de maio de 2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, conforme termos acostados aos autos e mídias que se encontram arquivadas em Cartório e disponível aos interessados.

Na fase do art. 402 do CPP, aplicável por analogia, nada foi requerido.

Em sede de debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, pois a despeito da negativa do réu, os policiais foram claros em dizer que ele teria mantido contato com um motociclista e então encontraram o restante dos entorpecentes. Os elementos são suficientes para demonstrar a narrativa de que o réu estava no local praticando o tráfico de drogas, conforme a denúncia repassada aos policiais. Também havia o dinheiro de origem desconhecida e o local é ponto de tráfico de drogas. O réu é primário e não se opõe à fixação da pena no patamar mínimo. Por outro lado, requer a fixação do regime fechado, sendo vedada a conversão.

A defesa insiste na desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas, porque não estava efetivamente traficando. As drogas estavam embaladas de forma divergente e não há ligação entre a droga encontrada com o réu e a encontrada no trailer. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Alternativamente, requer a concessão do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e requer o regime aberto.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 08) auto de constatação preliminar (págs. 09) e exame químico-toxicológico de pgs. 70/72.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o

princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Julio César de Araújo Zocal informa que na data dos fatos estava de serviço junto com a soldado Letícia e receberam informações de um morador, inconformado com o tráfico de drogas que ocorria diariamente no local da abordagem que é um trailler. O denunciante deu as características de um indivíduo que estava traficando no local e recordaram-se de terem visto um indivíduo semelhante e viram ele saindo da parte de trás do trailler. Nesse primeiro momento ele não foi abordado. Diante das informações deslocaram-se para o referido local e quando adentraram a avenida viram o réu em contato com um motociclista em uma Titan de cor preta que, ao visualizar a viatura, saiu em disparada no sentido oposto. O réu saiu caminhando. Foi abordado e em busca pessoal com ele havia certa quantia em dinheiro – R\$ 210,00 e uma porção de maconha. Como tinham visto ele, minutos antes, saindo das proximidades do trailler, fizeram a busca no local e localizaram a mesma droga que ele portava – maconha. Ele disse que desconhecia a droga e que era usuário de maconha. Sobre o dinheiro ele não informou a origem. Ele disse que não trabalhava e não informou como adquiriu o dinheiro. Ele já era conhecido pelo vulgo "Batatinha", como envolvido no tráfico de drogas. O modus operandi dele semelhante ao de tráfico. A porção na bermuda dele era com plástico branco e as demais em invólucros de plástico preto. Porém, ressalta que a porção que estava com ele aparentemente era para um único cigarro e as demais eram tabletes maiores para fins de comercialização. O réu aparentava ter bebido. Não aparentava que tinha usado maconha e não havia isqueiro e nem papel com ele.

Ana Letícia Avelar Zenardo de Souza informa que recebeu denúncia de um morador do bairro dizendo que não aguentava mais o tráfico no trailer e a pessoa passou as características de roupas que o réu estava. Não se lembra as características agora. Viram o réu se aproximando de uma motocicleta. A moto saiu em disparada. O réu tinha uma porção de droga na bermuda e R\$ 210,00 em dinheiro. Ele não soube declinar a origem. Não deu para visualizar ato de entrega. O réu é conhecido dos meios policiais. Logo que chegou em São José seu parceiro disse que conhecia ele dos meios policiais. Ele falou que era usuário. Não havia nada com ele para fumar maconha, nem papel, nem isqueiro. Quem toma conta do trailer é o tal de "Reginho" e era comum o tráfico lá. De uns dois meses para cá a situação "deu uma parada".

Jonathan Mateus Teixeira de Paula, nunca foi preso nem processado. Estava ajudando seu pai como servente. Tem 19 anos. Estudou até o primeiro colegial. Usa maconha todo dia. Ouviu o que os policiais disseram. No dia dos fatos eles falaram que acharam a droga atrás do trailler. Estava lá apenas pegando seu celular. Eles viraram na avenida, já estava indo embora. Estava apenas com um baseado que tinha pegado para ir embora. Eles então voltaram e apresentaram as cinco porções que não lhe pertencem. Disse que não manteve contato com a moto. Estava chegando na outra esquina que já desce. Se tivesse moto lá não ia dar nem tempo para ela se evadir. Já foi abordado pelo Cabo Zocal quando era menor.

2 -) DO DIREITO APLICÁVEL:

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela

defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não pode o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a proclamar: “Não compromete a credibilidade da palavra dos policiais eventual violência contra os presos ou variação sobre pormenores a respeito do fato criminoso.” (TJSP, Ap. 203.471-3/0, 5.^a Câmb. J. 26.9.1996, rel. Des. Dante Busana, RT 737/602).

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento discriminatório em violação do princípio da igualdade e temor de enfrentar o fato e o seu valor correspondente, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1.^a Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19.^a Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO,

Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que em se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a "lei do silêncio", extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

O réu foi visto pelos policiais tentando entregar algo a uma pessoa que estava passando de motocicleta. Ao abordarem o acusado, realizaram busca pessoal, onde foi localizado em poder do mesmo um invólucro de plástico de cor branca contendo maconha, que estava guardado no bolso da bermuda que trajava, além da quantia de R\$ 210,00.

O réu não justificou a origem do dinheiro. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e o réu somente foi abordado a partir de informação de um morador que, cansado da traficância naquela localidade, repassou aos policiais as características do traficante.

A dúvida capaz de favorecer o réu deve estar sustentada em contraprovas e não meramente a partir de hipóteses, sob pena de contemplar-se indevidamente a subjetividade e o "decisionismo".

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 - com destaques acrescentados pelo Juízo).

A negativa de autoria do réu nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade.

Por serem isentas, preponderam as provas acusatórias contra o réu e demais indícios de seu envolvimento na atividade criminoso objeto da denúncia.

A importância dos indícios "é inegável nos tempos atuais, quando, cada vez mais, o processo penal moderno necessita de instrumentos eficientes para, respeitando a intimidade de os direitos fundamentais alheios, produzir prova da culpa." "Não se deve desprezar a prova indiciária, tão-somente pelo fato de se tratar de prova indireta. Por vezes, é mais segura que qualquer prova direta."

É de se ressaltar que as normas incriminadoras (artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006) encerram uma potencialidade abrangente de duas condutas, dependendo da conduta do réu a justa e exata caracterização, como usuário ou traficante, exigindo, para o reconhecimento do tipo penal previsto no artigo 28 da lei 11.343/06, prova a ser produzida pela defesa de que a substância entorpecente não se destinava ao comércio ilícito.

Vale lembrar aqui o disposto no art. 156 do CPP: "A prova da alegação incumbirá a

quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:" (destaques do Juízo).

Assim, caberia à Defesa apontar e comprovar circunstâncias ou fatos concretos que pudessem invalidar o depoimento colhido dos policiais nestes autos. Sem isso o Juízo não deve desacreditar a prova acusatória, pois nada há de concreto que faça crer tenham procedido os agentes do Estado imbuído por sentimentos subalternos que mereçam censura.

Está desgastada a tese de perseguição, lançada ao léu por muitos e muitos réus, que tentam subverter os policiais em criminosos que pretendem encarcerar cidadãos inocentes, como se não tivessem criminosos o bastante para se ocupar.

A conclusão obtida neste Juízo é a de que neste processo obteve-se indícios graves, precisos e concordantes, hábeis a respaldar o raciocínio indutivo-dedutivo acerca da culpabilidade do réu.

As partículas do fato principal pinçadas nesta decisão revelam condições firmes e seguras que permitem visualizar o envolvimento de Jonathan Mateus Teixeira de Paula na prática de tráfico de entorpecentes.

Diante do panorama probatório, conclui-se que a conduta praticada pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal esculpido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (Nova Lei de Drogas), consideradas as circunstâncias que permearam a apreensão dos entorpecentes, ficando afastada a tese desclassificatória sustentada pela defesa.

Presente a tipicidade delitiva e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de pgs. 77/78 para CONDENAR JONATHAN MATEUS TEIXEIRA DE PAULA pela prática do crime capitulado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie. O réu é primário. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 63,5 gramas de maconha, massa líquida indicada nas pgs. 71.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo não encontra campo para acréscimo, pois não há quantidade-variedade de drogas diferentes e a quantidade de maconha não pode ser

considerada acima daquelas encontradas em apreensões corriqueiras nesta comarca.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não recomendam o acréscimo da pena base.

Não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, em 5 anos de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o réu é primário e a quantidade de entorpecentes não é suficiente para indicar ligação a organização criminosa.

Portanto, considerando que o réu é primário e a apreensão não possui dimensão suficiente para indicar que o réu integra organização criminosa deve ser beneficiado com o redutor em seu patamar máximo.

Deste modo, reduzo a pena em 2/3 fixando-a em 01 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Donde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

Evidentemente que as instâncias ordinárias deverão observar se o entendimento se firmará e quais serão seus demais contornos e reflexos. Ressalvo, ainda, meu posicionamento pessoal sobre a maior adequação do regime inicial fechado para os casos de tráfico de entorpecente, que se sustentava, entretanto, também em sua

equiparação a crime hediondo.

Em matéria disponível no site "Conjur", divulgada em 2016, verifica-se que novamente o E. STF entendeu pela impossibilidade de fixação do regime fechado aos casos de tráfico privilegiado. As decisões são do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli e foram proferidas em dois pedidos de HC impetrados pelo defensor público Alexandre Orsi Netto, que atua em Sorocaba.

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

No Habeas Corpus nº 457.359/SP (2018/0162657-9), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 23.08.2018 o E. STJ reafirmou a mudança de posicionamento quanto ao tema por parte da Quinta e Sexta Turmas daquela Corte Superior, que culminou na revisão do entendimento anteriormente consolidado, pela Terceira Seção, e no cancelamento do Enunciado nº 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

A este respeito também é devida observância à súmula 440 do STJ, bem como 718 e 719 do STF, as quais também orientam a fixação do regime, ou ainda o teor da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal.

Eis o teor das súmulas citadas:

SÚMULA Nº 440 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

SÚMULA Nº 718 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

SÚMULA Nº 719 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Com tais fundamentos, fixo o regime ABERTO, considerando os precedentes supra, primariedade do réu e pequena quantidade de droga apreendida.

Inviável, no entanto, a substituição da pena, a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 - SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 - SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que "se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa - e com maior razão."

Em meu entendimento, não se afigura socialmente recomendável a reinserção de

traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestar serviços comunitários.

Ademais, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semi-aberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

Fica suspensa a cobrança na forma do § 3º do art. 98 do NCPC c/c art. 3º do CPP, pois o réu está patrocinado por advogado dativo.

Honorário na forma do convênio OAB-DPE. Expeça-se certidão, na ordem dos serviços.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão observando o regime fixado. Faculta-se ao réu apresentar-se em Juízo no horário das 13:00 às 16:30 durante os dias úteis, ocasião em que sua audiência admonitória será "encaixada" na pauta regular, evitando-se o cumprimento de mandado de prisão em regime aberto pela Polícia a fim de prevenir eventuais intempéries que excepcionalmente podem ocorrer em situações análogas; Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal; Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois ausente demonstração de origem lícita os elementos são seguros a indicar tratar-se de proveito do crime de tráfico de drogas.

Sao Jose do Rio Pardo, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA